Lesione dei diritti fondamentali e doppia pregiudizialità

Traccia: *Lesione dei diritti fondamentali e doppia pregiudizialità (costituzionale ed eurounitaria). Si soffermi il candidato sui poteri del giudice amministrativo.*

Scaletta

1. **Introduzione.** La tutela multilivello dei diritti fondamentali: Costituzione, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CEDU. Il giudice comune come snodo tra i diversi sistemi.
2. **Le due pregiudizialità.** Questione di legittimità costituzionale (accentramento, art. 134 Cost.; art. 23 l. n. 87 del 1953) e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE). Primato del diritto dell'Unione e non applicazione della norma interna (Simmenthal, Granital); controlimiti. Ambito di applicazione della Carta (art. 51; Åkerberg Fransson). Differenza con la CEDU (norme interposte ex art. 117, comma 1, Cost.; sentenze gemelle del 2007).
3. **La doppia pregiudizialità.** Il problema delle norme interne che violano diritti tutelati sia dalla Costituzione sia dalla Carta. L'impostazione tradizionale (priorità della pregiudiziale europea). La svolta della sentenza n. 269 del 2017 e la sua correzione con le sentenze n. 20 e n. 63 del 2019: libertà del giudice comune, rinvio pregiudiziale in ogni fase, non applicazione all'esito. Il dialogo diretto con la Corte di giustizia (ordinanza n. 117 del 2019). I limiti posti dalla Corte di giustizia (Melki e Abdeli, 2010).
4. **I poteri del giudice amministrativo.** Giudice a quo e giudice del rinvio; obbligo di rinvio del Consiglio di Stato come giudice di ultima istanza (CILFIT; Consorzio Italian Management, 2021); rapporto con l'Adunanza plenaria (art. 99 c.p.a.; Puligienica, 2016). Non applicazione della legge e dei regolamenti; provvedimento amministrativo contrastante con il diritto dell'Unione (annullabilità, autotutela, Kühne & Heitz). Tutela cautelare (Factortame) e questione sollevata in sede cautelare. Interpretazione conforme. Limiti del sindacato della Cassazione (Corte cost. n. 6 del 2018; Randstad, 2021). Giurisdizione del giudice amministrativo sui diritti fondamentali (Corte cost. n. 140 del 2007).
5. **Conclusione.** Il giudice amministrativo come giudice dei diritti fondamentali nel sistema integrato; la scelta della via più adatta come esercizio di una responsabilità, non di un automatismo.

Tema

La tutela dei diritti fondamentali si sviluppa oggi su più livelli, che si intersecano senza ordinarsi in una gerarchia rigida. Accanto alla Costituzione, che li riconosce e garantisce come inviolabili all'art. 2, operano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la cui interpretazione è affidata alla Corte di Strasburgo. Ciascuno di questi sistemi ha il proprio giudice di vertice e i propri strumenti di garanzia, ma tutti convergono, nel momento applicativo, sul giudice comune, chiamato a risolvere la controversia concreta e quindi a scegliere quale strada percorrere quando la norma interna da applicare appaia lesiva di un diritto fondamentale. Il problema della cosiddetta doppia pregiudizialità nasce proprio da questa convergenza: quando la stessa disposizione legislativa contrasta sia con la Costituzione sia con il diritto dell'Unione, il giudice deve decidere se sollevare la questione di legittimità costituzionale, se rivolgersi alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale o se, ricorrendone i presupposti, non applicare direttamente la norma interna. Per il giudice amministrativo la questione assume un rilievo particolare, perché egli è chiamato quotidianamente a misurare l'azione dei pubblici poteri con i diritti dei privati, e dispone di strumenti processuali peculiari, dalla tutela cautelare all'annullamento dei provvedimenti.

Per comprendere i termini del problema occorre muovere dalla diversa struttura delle due pregiudizialità. Il nostro ordinamento ha adottato un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, nel quale soltanto la Corte costituzionale può dichiarare l'illegittimità di una legge (art. 134 Cost.). Il giudice comune, se ritiene rilevante e non manifestamente infondata una questione, sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte (art. 23 della legge n. 87 del 1953), dopo aver verificato l'impossibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione; la Corte ha infatti chiarito, già nel 1996, che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Il rapporto con il diritto dell'Unione segue invece una logica diffusa. In forza del principio del primato, affermato dalla Corte di giustizia sin dal 1964 [Costa c. Enel] e precisato con una sentenza del 1978 [Simmenthal], il giudice nazionale deve applicare integralmente il diritto dell'Unione direttamente applicabile, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi norma interna contrastante, anteriore o successiva, senza attenderne la rimozione da parte del legislatore o della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha recepito questa impostazione con una sentenza del 1984 [Granital], ricostruendo il rapporto tra i due ordinamenti come rapporto tra sistemi autonomi ma coordinati, nel quale la norma interna incompatibile non è invalida, ma semplicemente non applicata nella materia riservata al diritto dell'Unione. Resta fermo il limite dei controlimiti, cioè dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona, che non possono essere sacrificati neppure dal diritto dell'Unione e la cui tutela

spetta alla sola Corte costituzionale. Quando il giudice dubita dell'interpretazione o della validità del diritto dell'Unione, lo strumento è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, facoltativo per i giudici di merito e obbligatorio per quelli di ultima istanza.

Il sistema della CEDU segue ancora una logica diversa. Con le sentenze gemelle del 2007 [nn. 348 e 349] la Corte costituzionale ha escluso che le norme della Convenzione, prive dei caratteri del diritto dell'Unione, possano essere direttamente applicate dal giudice comune in luogo della legge interna contrastante. Esse operano come norme interposte, la cui violazione si traduce in un contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., che deve essere fatto valere sollevando questione di legittimità costituzionale, dopo aver tentato un'interpretazione convenzionalmente conforme. Ne risulta un quadro in cui la lesione di un diritto fondamentale riceve un trattamento diverso secondo la fonte che lo garantisce, e in cui la Carta di Nizza occupa una posizione intermedia e delicata. La Carta, infatti, fa parte del diritto dell'Unione e gode del primato, ma il suo contenuto coincide in larga parte con quello della Costituzione e della CEDU; inoltre essa si applica agli Stati membri soltanto nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51), nozione che la Corte di giustizia, con una sentenza del 2013 [Åkerberg Fransson], ha inteso in senso ampio, come estesa a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione.

È in questo spazio che si colloca la doppia pregiudizialità. Secondo l'impostazione tradizionale, quando una norma interna risultava in contrasto sia con la Costituzione sia con il diritto dell'Unione, la questione europea aveva carattere preliminare: il giudice doveva prima verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione, se del caso con il rinvio pregiudiziale, e procedere alla non applicazione, perché la questione di costituzionalità sarebbe stata altrimenti irrilevante, avendo il giudice il potere di risolvere da sé il contrasto. Questo assetto è stato messo in discussione dalla Corte costituzionale con una sentenza del 2017 [n. 269]. In un passaggio di carattere generale, la Corte ha osservato che la Carta dei diritti ha un contenuto di impronta tipicamente costituzionale e che le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes della Corte costituzionale, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità a fondamento dell'architettura costituzionale. Ne ha tratto la conclusione che, nei casi in cui una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione quanto a quelli garantiti dalla Carta, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale. La ratio della svolta è chiara: evitare che la tutela dei diritti fondamentali si frammenti in una serie di non applicazioni con effetti limitati al singolo giudizio, e riaffermare il ruolo della Corte costituzionale come garante della certezza del diritto attraverso pronunce con efficacia generale.

L'affermazione, tuttavia, poneva un problema di compatibilità con il diritto dell'Unione. La Corte di giustizia aveva infatti chiarito, già con una sentenza del 2010 [Melki e Abdeli], che un meccanismo nazionale che attribuisca priorità al controllo di costituzionalità è compatibile con l'art. 267 TFUE soltanto se il giudice comune resta libero di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento e anche dopo la decisione della Corte costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale ritenga necessaria, di adottare misure provvisorie di tutela dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione e di disapplicare, al termine del procedimento incidentale, la norma interna ritenuta contraria al diritto dell'Unione. Proprio in questa direzione si è mossa la stessa Corte costituzionale con due sentenze del 2019 [nn. 20 e 63], che hanno corretto l'impostazione del 2017. La Corte ha precisato che il giudice comune conserva il potere di sottoporre alla Corte di giustizia, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a suo avviso necessaria, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e di non applicare, ove ne ricorrano i presupposti, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. La priorità della questione di costituzionalità non è dunque più un obbligo, ma un'opzione rimessa alla valutazione del giudice, che può scegliere la via ritenuta più adeguata al caso concreto. In questo nuovo assetto la Corte costituzionale ha mostrato di voler partecipare direttamente al dialogo con la Corte di giustizia: emblematica è un'ordinanza del 2019 [n. 117], con cui la Corte ha essa stessa proposto un rinvio pregiudiziale in materia di diritto al silenzio nei procedimenti sanzionatori della Consob, recependo poi la risposta della Corte di giustizia nella propria decisione. Il risultato è un sistema di concorso di rimedi, nel quale il giudice comune non è più costretto a una sequenza rigida, ma deve scegliere consapevolmente lo strumento più idoneo, tenendo conto anche dell'eventuale opportunità di una pronuncia con efficacia erga omnes.

È in questo quadro che si colloca il ruolo del giudice amministrativo, i cui poteri risultano particolarmente ampi e articolati. Egli è anzitutto giudice a quo, e può sollevare la questione di legittimità costituzionale quando la legge che fonda il provvedimento impugnato appaia lesiva di un diritto fondamentale, sospendendo il processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. Al tempo stesso è giudice del rinvio pregiudiziale, e quando decide in ultima istanza, come accade di regola per il Consiglio di Stato, è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia, salvo che la questione non sia rilevante, che la disposizione sia già stata interpretata dalla Corte o che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciare spazio a ragionevoli dubbi. Si tratta dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia nel 1982 [CILFIT], che la stessa Corte ha ribadito e precisato proprio su rinvio del Consiglio di Stato con una sentenza del 2021 [Consorzio Italian Management], chiarendo che il giudice di ultima istanza deve motivare la scelta di non procedere al rinvio e che l'assenza di ragionevoli dubbi va valutata anche alla luce delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione. Il dovere di rinvio prevale anche sulla regola nazionale che vincola le sezioni del Consiglio di Stato ai

principi enunciati dall'Adunanza plenaria (art. 99, comma 3, c.p.a.): la Corte di giustizia, con una sentenza del 2016 [Puligienica], ha affermato che la sezione che non condivida l'orientamento della Plenaria, per ragioni attinenti al diritto dell'Unione, può e anzi deve rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia.

Accanto ai poteri di rinvio, il giudice amministrativo dispone del potere di non applicare la legge interna contrastante con il diritto dell'Unione direttamente applicabile, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire da una sentenza del 1989 [Fratelli Costanzo], spetta anche alla stessa pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa ammette inoltre la disapplicazione dei regolamenti contrastanti con norme di rango superiore, anche quando non siano stati tempestivamente impugnati. Diverso è il regime del provvedimento amministrativo adottato in violazione del diritto dell'Unione: l'orientamento prevalente lo considera annullabile e non nullo, sicché deve essere impugnato nel termine di decadenza, in coerenza con il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nei limiti dell'equivalenza e dell'effettività. Il principio della certezza del diritto giustifica la stabilità del provvedimento non impugnato; la Corte di giustizia, con una sentenza del 2004 [Kühne & Heitz], ha tuttavia individuato le condizioni in presenza delle quali l'amministrazione è tenuta a riesaminare una decisione definitiva, alla luce di una successiva interpretazione del diritto dell'Unione, quando il diritto nazionale le riconosca un potere di riesame.

Particolarmente significativo è il terreno della tutela cautelare, nel quale si misura l'effettività della protezione dei diritti fondamentali, garantita anche dall'art. 47 della Carta. La Corte di giustizia, con una sentenza del 1990 [Factortame], ha affermato che il giudice nazionale deve poter concedere provvedimenti provvisori a tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, disapplicando la norma interna che glielo impedisca. Sul versante interno, la giurisprudenza costituzionale ammette che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata in sede cautelare, purché il giudice non abbia esaurito la propria potestas iudicandi, come accade quando concede la misura in via provvisoria, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo la decisione della Corte. Il giudice amministrativo può dunque assicurare una tutela immediata del diritto fondamentale leso, senza attendere l'esito della questione incidentale o del rinvio pregiudiziale. A ciò si aggiunge il dovere di interpretazione conforme, sia a Costituzione sia al diritto dell'Unione, che costituisce il primo strumento a disposizione del giudice e che deve essere esperito prima di ogni rimessione.

Due ulteriori profili completano il quadro. Il primo riguarda i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost.). La Corte costituzionale, con una sentenza del 2018 [n. 6], ha escluso che tale nozione possa estendersi alla violazione del diritto dell'Unione, e la Corte di giustizia, con una sentenza del 2021 [Randstad Italia], ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione l'assetto così delineato. Ne consegue che il giudice amministrativo di

ultima istanza è il garante finale dell'applicazione del diritto dell'Unione nelle materie di sua competenza, il che accresce la responsabilità connessa al suo obbligo di rinvio. Il secondo profilo riguarda la stessa giurisdizione amministrativa sui diritti fondamentali. Alla tesi che riservava al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, ritenuti non degradabili dal potere amministrativo, la Corte costituzionale ha opposto, con una sentenza del 2007 [n. 140], che non esiste alcun principio che riservi in via esclusiva al giudice ordinario la tutela dei diritti fondamentali, ben potendo il legislatore attribuirla al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva, in quanto anch'egli idoneo a offrire piena tutela.

In conclusione, la doppia pregiudizialità non si presenta più come un conflitto tra Corti da risolvere attraverso una gerarchia rigida tra rimedi, ma come un sistema di strumenti concorrenti, affidati alla scelta responsabile del giudice comune. Dopo la sentenza del 2017 e le successive precisazioni del 2019, il giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale quando ritenga necessaria una pronuncia con efficacia generale, proporre il rinvio pregiudiziale quando occorra chiarire la portata del diritto dell'Unione, o non applicare la norma interna quando il contrasto con una norma europea direttamente applicabile sia evidente. Il giudice amministrativo, che dispone della tutela cautelare, del potere di annullamento e di quello di non applicazione e che è spesso giudice di ultima istanza, occupa in questo sistema una posizione centrale. La sua funzione non è soltanto quella di controllare la legittimità dell'azione amministrativa, ma anche quella di assicurare che la tutela dei diritti fondamentali sia piena ed effettiva, valorizzando il dialogo tra le Corti come strumento per elevare, e non per frammentare, il livello di protezione della persona.